

1502713-83.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... estiveram no local conhecido pelo tráfico, um matagal onde havia um barraco. Surpreenderam o réu e um menor, então, contando as drogas e o dinheiro das vendas. Destacou que os dois confessaram informalmente que estavam no tráfico. Uma parte da maconha estava numa sacola.

Como se percebe, os fatos narrados na exordial acusatória restaram devidamente comprovados. No dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502713-83.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502713-83.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2289577/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 20990286 - 07º D.P. GUARULHOS, 3347/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2289577 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WLENER BOMFIM MARQUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Glaucio Roberto Brittes de Araujo

VISTOS.

WLENER BOMFIM MARQUES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo

processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 11h, na Rua José Mantovani, altura do nº 37, Bairro Ponte Alta, Bairro Bonsucesso, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com o adolescente Cicero Erlânio da Silva, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 88 porções contendo 56,59g de cocaína, 29 porções contendo 8,41g de crack e 44 porções contendo 24,08g de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente conhecida por "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 13/14, laudo de constatação provisória contendo fotografias a fls. 16/21 e exame químico-toxicológico a fls. 63/65.

O réu foi notificado (fls. 93) e apresentou resposta (fls. 167/168, 173/181). A denúncia foi recebida (fls. 184/185). Não tendo ocorrido absolvição sumária, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Em instrução regular, foi ouvida uma testemunha comum à acusação e defesa e o acusado foi interrogado.

Superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia, com aumento da pena pelo disposto no art. 40, admitindo o redutor no percentual intermediário, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, por sua vez, postulou fixação da pena no mínimo legal, atenuante da confissão, aplicação do redutor do par. 4 no patamar máximo, regime aberto e substituição por restritivas de direito.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal procede.

A materialidade está provada, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, Autos de Constatação de Substâncias Entorpecentes e Laudo Pericial, cujas conclusões foram positivas para Cocaína e Tetrahydrocannabinol, e prova oral.

A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão de dinheiro, as circunstâncias da posse e a confissão inicial evidenciam que o entorpecente seria fornecido a terceiros. A conduta corresponde, perfeitamente, ao tipo penal do art. 33, da Lei 11.343/06. A autoria é igualmente certa.

O réu confessou plenamente a prática delitativa, admitindo ser usuário de maconha, mas salientando que consegue ficar sem o consumo e que tem registros em carteira de trabalho. Destacou que tem filho pequeno e que estava em dificuldades financeiras. A confissão encontrou sólido respaldo probatório. Vejamos.

O policial Paulo Cesar declarou que, em razão de inúmeras denúncias, estiveram no local conhecido pelo tráfico, um matagal onde havia um barraco. Surpreenderam o réu e um menor, então, contando as drogas e o dinheiro das vendas. Destacou que os dois confessaram informalmente que estavam no tráfico. Uma parte da maconha estava numa sacola.

Como se percebe, os fatos narrados na exordial acusatória restaram devidamente comprovados. No dia aludido, o acusado determinado a realizar o comércio ilícito de drogas na região, uniu-se ao adolescente Cicero Erlânio da Silva e, em local conhecido por ser ponto de tráfico, passou a separar dezenas de porções contendo

cocaína, crack e “maconha” e a fazer a contabilidade do tráfico de drogas, com a finalidade de apurar o valor auferido com as vendas efetuadas.

Com efeito, observa-se que a confissão judicial encontrou sólido amparo nas provas produzidas. Não permaneceu isolada e foi corroborada por várias declarações. Nenhum dado concreto a abalou. Não há que se falar, portanto, em eventual insuficiência, por seu valor relativo, da confissão judicial, já que esta, no caso dos autos, está amparada por vários elementos probatórios, mormente depoimentos harmônicos. Nesse sentido, transcreve-se lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(..) a confissão ganha qualquer outra prova. Até certo ponto ela as transcende; elemento no cálculo da verdade, ela é também o ato pelo qual o acusado aceita a acusação e reconhece que esta é bem fundamentada; transforma uma afirmação feita se ele em uma afirmação voluntária. Pela confissão, o próprio acusado toma lugar no ritual de produção da verdade penal”. (Código de Processo Penal Comentado, 12^a ed., São Paulo: RT, 2012, p. 470).

Ademais, o policial narrou, com detalhes, coerência e firmeza, a atitude suspeita do réu, a posse das drogas prontas para venda e do produto da já realizada e a confissão espontânea, enquanto a defesa não soube relatar dinâmica diversa e não cogitou de motivo para ser incriminado falsamente. Não é crível, outrossim, que aquela quantidade e variedade de drogas se destinariam apenas ao uso pessoal, sobretudo em várias porções.

As provas do manuseio para comércio são fartas e não era imprescindível a abordagem de destinatário da substância, embora conveniente. A medida poderia frustrar o resultado do flagrante. Além disso, não há razão concreta para desprezar as declarações de testemunhas sob compromisso formal, inclusive sobre o porte para vendas e a confissão espontânea. Saliente-se que merecem crédito e são dotados de valor probatório determinante, em delitos de tal jaez. Nesse sentido, há farta jurisprudência:

“O valor de depoimento testemunhal de policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC nº 73.518-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.1996).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POR POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. (...) 2. Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida - 24 (vinte e quatro) invólucros com crack - revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 3. Tem-se por adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena corporal de 5 (cinco) anos aplicada ao paciente pelo tráfico de drogas, dado o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal em conta do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas, não se olvidando a quantidade de entorpecente que trazia consigo. 4. Ordem denegada.” (STJ, HC n.º 223086 / SP; 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.11.2013).

Nesse sentido, o relato do policial, coerentes nas duas fases processuais, minucioso, harmônico, seguro e condizente com os elementos sensíveis da infração, merece prestígio. Não havia motivos, a propósito, para incriminar falsamente um desconhecido. Também não sugeriram indícios de que a droga pertencesse a outrem ou de

equivoco no flagrante.

E o decreto condenatório não se baseia tão somente na confissão do acusado ou nos dados do inquérito. No caso concreto, todos os elementos probatórios harmonizam-se, inclusive aqueles obtidos na fase judicial, sendo certo que o magistrado pode utilizar todos na formação de seu convencimento. Ainda que assim não fosse, não há óbice à valoração, embora relativa, dos elementos colhidos na fase de investigação para fundamentar eventual decreto condenatório, porquanto a vedação legal é no sentido da impossibilidade de condenação lastreada exclusivamente em tais provas, nos exatos termos do art. 155 do CPP. Neste sentido, é a jurisprudência:

"(...) Mostra-se válida a condenação imposta com auxílio de dados obtidos na fase inquisitorial se tais estão em consonância com o apurado em juízo. O desprezo ao que se produziu na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em nosso ordenamento. Portanto, ainda que tenha a princípio menor valor o elemento produzido no caderno inquisitivo, por força do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode tal ser afastado de pronto. No caso dos autos a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, confirma e corrobora a prova produzida tão somente no inquérito policial. Assim a prova deve ser vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida, mas o valor probante, estando garantido os direitos constitucionais do réu, conforme acima exposto". (TJ/SP, Apelação nº 0039765-66.2010.8.26.0506, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 28/04/2016).

No mais, em delitos de tal natureza, as evidências são determinantes para elucidação do vínculo subjetivo entre o agente e as drogas e de sua destinação, sendo inviável prova concreta e cabal do seu pensamento. De outro lado, não se alegou pronta e espontaneamente e não ficou evidenciado que toda aquela droga apreendida seria consumida.

De qualquer sorte, a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, a confissão, a posse de dinheiro e as circunstâncias da ação revelaram sobejamente a destinação a terceiros. Até mesmo o usuário pode comercializar, sobretudo para sustentar o vício. Incabível, pois, eventual tese de insuficiência de provas ou desclassificação para art. 28, da lei.

O acusado é imputável e praticou os atos típicos descritos na norma penal. Justificativas relativas à situação econômica, ainda que, em tese, tivessem contribuído para a traficância, não são dirimentes da ilicitude ou da culpabilidade. Não justificam a despicienda ofensa ao bem jurídico.

Ficou comprovada, ainda, a incidência da cauda de aumento prevista no art. 40, VI ambos da Lei n. 11.343/06, porque inegável o envolvimento do menor, que estava com o réu na mercancia. Esse tinha o conhecimento de sua idade evidente. Jamais o negou, além de cognoscível sua condição de vulnerabilidade. Ressalte-se que a lei contenta-se com a circunstância objetiva, prejudicial ao desenvolvimento do menor, e prescinde da corrupção exercida pelo acusado, que configura outro crime. Basta que este aceite a realização do crime nessas condições, contribuindo para as consequências perniciosas sobre o adolescente. Nenhuma prova de que não sabia da sua menoridade (o que jamais alegou), visível e cognoscível, aliás, a qualquer um, foi produzida. Ademais, despicienda a ascendência sobre ele, embora revelada pelas circunstâncias do flagrante.

Finalmente, nenhum álibi restou comprovado de maneira inequívoca e nenhuma excludente ficou configurada. Não pairam dúvidas sobre o liame subjetivo entre o réu e as drogas encontradas e sobre a finalidade de fornecimento a outrem.

Portanto, comprovada a materialidade delitiva e evidenciada a autoria, ante o complexo probatório robusto e coerente produzido nos autos, impende apreciar a dosimetria da pena fixando-a no patamar suficiente e necessário à reprovação do

delito.

Bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, tendo em vista a primariedade (fls. 38/39), na primeira fase, fixo a pena-base consistente em 5 (anos) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A quantidade já é considerada na configuração da destinação a terceiros e no emprego de redução menor na terceira fase, não sendo usada aqui para majoração, sob pena de bis in idem.

Na segunda fase, resta prejudicada a atenuante da confissão espontânea, haja vista a impossibilidade de redução da pena aquém no mínimo legal, nesta fase.

Na terceira etapa, incide uma causa de aumento (envolvimento de um menor), justificando-se majoração apenas de 1/6 (um menor), que resulta pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Por outro lado, em razão dos bons antecedentes e ausência de provas de envolvimento em atividade criminosa, incide a causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 em 1/2 da pena, fixando-a em 2 anos e 11 meses de reclusão, além de 291 dias-multa. Da mera quantidade não se extrai filiação a grupo de tal espécie ou mesmo dedicação permanente à atividade ilícita organizada. Embora comum nestes casos, seria necessário elemento concreto convincente a respeito do vínculo. Sequer foi obtida, outrossim, sob o crivo do contraditório, prova da condição de integrante de grupo especializado ou de encargo duradouro e relevante em tal atividade. A realização por poucos dias ou de algumas vendas também poderia ser eventual, sem configurar propriamente dedicação à atividade criminosa.

Considerando, assim, a quantidade e espécie de parte do entorpecente (cocaína), mais lesiva à saúde do que outras, de um lado, e a função de pequeno varejo e o arrependimento revelado em confissão, de outro, a reprimenda é reduzida no patamar de 1/2, perfazendo 2 anos e 11 meses de reclusão, além de 291 dias-multa.

À míngua de critérios seguros e explicitamente estabelecidos para a aplicação do art. 33, par. 4, da Lei 11343/06, o art. 42 do referido diploma legal deve orientar o patamar daquela redução. Restringir este preceito à fase do art. 59, do Código Penal, a par de despiciendo, criaria distinção injustificada em relação a outros delitos, na primeira etapa de dosimetria da pena, e não permitiria solução eficaz para a controvérsia acerca dos critérios de redução da terceira fase. Por conseguinte, no caso em apreço, ante a quantidade e natureza da droga, não cabe a redução máxima, estando preservado o prudente arbítrio do julgador.

A propósito, a lei estabelece somente que as penas “poderão” ser reduzidas. Além disso, entende-se que por se tratar de causa de redução - que pode ir aquém do mínimo legal - e não de dosimetria da primeira fase, não se adota a pena menor em perspectiva (diminuição máxima) como regra. Muito pelo contrário, a legislação recente destinou-se ao agravamento da coibição, da repressão e da resposta penal para o tráfico de entorpecentes, sendo ilógica e dissociada do princípio da razoabilidade a exigência peremptória da diminuição máxima da pena, que a levaria a um patamar muito inferior ao da lei antiga.

Segundo exegese sistemática e teleológica, o percentual de diminuição deve ser escolhido de acordo com o caso concreto, o grau de culpabilidade e especificidade do potencial lesivo da conduta, como possível número de usuários em perspectiva e danos à saúde destes. Assim, nega-se a diminuição máxima, sobretudo por haver cocaína. Em contrapartida, a função desempenhada (varejo e não gerência) e as condições subjetivas aparentes não se coadunam com a redução mínima. Não havendo mais causas de diminuição ou de aumento, a reprimenda permanece no patamar anteriormente fixado.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, tendo em vista a quantidade da pena, a natureza do crime (sem violência ou ameaça) e as

circunstâncias favoráveis do artigo 59, do CP. Por se tratar de tráfico de drogas privilegiado, cumpre observar decisões recentes dos Tribunais Superiores no sentido de que o referido crime não é hediondo e enseja regime compatível com a quantidade da pena. Sobre a temática, confira-se:

EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE". (STJ, HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1) - Decisão Monocrática- Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

Ademais, tal conclusão também decorre da Lei de Execuções Penais, com as alterações trazidas pelo pacote anticrime (Lei n.º 13.964/2019), mais precisamente da redação art. 112, § 5º da LEP: "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006."

Preenchidos ainda os requisitos do art. 44, do CP, à luz da primariedade e da pena aplicada, e sendo socialmente recomendável, concede-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena e prestação pecuniária de um salário-mínimo a uma entidade com função social, especificadas oportunamente pelo juízo da execução.

Ante todo o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão do Órgão Ministerial para CONDENAR o réu WLENER BOMFIM MARQUES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação gratuita de serviços à comunidade pelo prazo da pena e prestação pecuniária de um salário-mínimo a uma entidade com função social, especificadas oportunamente pelo juízo da execução, além de 291 dias-multa pelo valor unitário mínimo.

O réu poderá apelar em liberdade, pois concedida a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura Clausulado, em favor do acusado. Transitada esta em julgado, far-se-á a necessária comunicação ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para o fim previsto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Declaro o perdimento do dinheiro em favor da União, ante as evidências da relação com o tráfico, e determino a incineração da droga apreendida.

Custas e despesas processuais pelo sentenciado, observada a gratuidade.

P.I.C.

Guarulhos, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA